

1500180-62.2021.8.26.0306

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Natália Berti

Comarca: José Bonifácio

Foro: Foro de José Bonifácio

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 25/10/2022

... entorpecentes dentro de um veículo - Réu que confessou o crime de tráfico - acusado que franqueou a entrada dos Policiais em sua residência, o que culminou na apreensão de uma balança de precisão - objeto que se mostra como mero instrumento para a consecução do crime tráfico de drogas no caso concreto - ausência de outros petrechos para o tráfico na residência do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de José Bonifácio

Foro de José Bonifácio

2ª Vara

Av. Monsenhor, 1000, Jardim das Palmeiras - CEP 15200-000, Fone: (17)3245-3348,

José Bonifacio-SP - E-mail: josebonif2@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500180-62.2021.8.26.0306

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2074564/2021 - DEL.POL.JOSE BONIFACIO, 11611156 - DEL.POL.JOSE BONIFACIO,

1647/20/321 - DEL.POL.JOSE BONIFACIO, 2074564 - DEL.POL.JOSE BONIFACIO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELSON ROMEIRO DE SOUZA

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

*

1. Aos 25 de outubro de 2022, às 14:30 horas onde presente estava o(a) Meritíssimo(a) Juiz(a), Senhor(a) Doutor(a) NATÁLIA BERTI foi aberta audiência designada nos autos supramencionados. conforme os termos do Comunicado 284/2020, emitido pelo E. Tribunal de Justiça, considerando a pandemia vivenciada (COVID-19).
2. Feito o pregão, verificou-se o seguinte: PRESENTE o(a) DD Promotor(a) de Justiça e Representante do Ministério Público, Senhor(a) Doutor(a) CÉSAR BOCUHY BONILHA; PRESENTES oa(s) ré(u)(s) ELSON ROMEIRO DE SOUZA e seu/sua Defensor(a) Dr(a). BEATRIZ DE SOUZA ROSSI; PRESENTES também as testemunha(s) FERNANDO BERTONI DA SILVA FRANCISCO, PAULO HENRIQUE MODONEZE COSTA.
3. Iniciados os trabalhos, o(a)(s) réu/ré(s) declararam expressamente que conversaram com o(a) seu/sua Defensor(a) antes da realização desta audiência, garantindo-se ainda ao(s) réu/ré(s) e a seu/sua Defensor(a) todos os meios assecuratórios da ampla defesa e contraditório. Na oportunidade, a MM Juíza advertiu a todos acerca do Comunicado 284/2020, bem como prestou maiores informações sobre a realização de videoconferência e das circunstâncias acerca da

pandemia vivenciada.

Após, o(a) Meritíssima Juiz(a) ouviu as Testemunha(s) FERNANDO BERTONI DA SILVA FRANCISCO, PAULO HENRIQUE MODONEZE COSTA.

Por fim, a Meritíssima Juíza realizou o Interrogatório do(a)(s) Ré(u)(s) ELSON ROMEIRO DE SOUZA

4. Então, a Meritíssima Juíza DECLAROU FINDA A INSTRUÇÃO e concedeu a palavra à Acusação e à Defesa, nesta ordem, para a apresentação dos memoriais e alegações finais orais. O(A) DD Promotor(a) de Justiça manifestou-se oralmente e o conteúdo de sua manifestação foi gravado por meio audiovisual. Por seu turno, a Defesa também ofereceu alegações finais orais em audiência, cujo teor foi gravado para posterior reprodução.

5. Terminados os debates, a Meritíssima Juíza proferiu a seguinte SENTENÇA:

Vistos.

ELSON ROMEIRO DE SOUZA, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, e artigo 34, ambos da Lei n.º 11.343/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal, porque, no dia 01 de novembro de 2020, por volta das 21h10, na Rua Abílio Catelan, nº 870, nesta Cidade e Comarca de José Bonifácio, ELSON ROMEIRO DE SOUZA, qualificado a fls. 11, guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico, 6,8 (seis gramas, oitocentos miligramas) de tetrahidrocannabinol - "THC", divididos em 03 porções, substância entorpecente e que determina dependência física e psíquica, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Auto de Exibição e Apreensão da droga de fls. 07/08 e Laudo Pericial Definitivo de fls. 15/17).

Consta, por fim, que, nas mesmas circunstâncias de tempo, ELSON ROMEIRO DE SOUZA, qualificado a fls. 11, possuía e guardava, ainda que gratuitamente, instrumento/objeto destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Conforme apurado, no dia e local dos fatos, policiais militares durante fiscalização de ocorrência de tráfico, avistaram o denunciado e um indivíduo não identificado sob uma árvore, que ao notarem a aproximação policial, tentaram fugir, e o denunciado jogou algo no chão, tendo somente ele sido abordado.

Em revista pessoal, nada foi encontrado, todavia localizaram o objeto que o denunciado havia dispensado, sendo a quantia de R\$ 90,00.

Inquirido, o denunciado confessou propriedade de entorpecente em sua casa, alegando ser para uso próprio.

Na sequência, franqueada a entrada no imóvel pelo denunciado, foi localizada e apreendida três porções de substância entorpecente, e na área externa da casa do denunciado, foi encontrada uma balança precisão, que após realização de perícia, restou positiva para presença de resquícios de cocaína (fls. 20/22).

Auto de Exibição e Apreensão da droga de fls. 07/08 e Laudo Pericial Definitivo de fls. 15/17.

As circunstâncias da apreensão, bem como a quantidade da droga, a balança precisão com resquícios de cocaína, o dinheiro dispensado no chão pelo denunciado, somado à diversas denúncias do envolvimento do denunciado com a mercancia ilícita (fls. 61/68) autorizam a capitulação da conduta como tráfico. Além disso, o objeto apreendido em sua residência destinava-se à preparação da droga para a venda.

A denúncia foi recebida em 21 de julho de 2022 (fls. 122/123). O acusado foi notificado (fl. 112), e apresentou resposta à acusação (fl. 118). Designada audiência de instrução, debates e julgamento, em audiência foram ouvidas as testemunhas e o réu foi interrogado.

O Ministério Público pediu a condenação, nos termos da denúncia.

O defensor pediu a absolvição do réu.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O processo encontra-se formalmente em ordem, não havendo nulidades ou vícios a serem sanados. O réu foi representado por Defensor e foram observados os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Não há questões preliminares a serem analisadas. Assim, passo ao mérito.

Assim, passo à análise do mérito.

A pretensão punitiva é PARCIALMENTE PROCEDENTE, pois as provas são suficientes para condenação apenas quanto ao delito do artigo 33, da Lei 11.434/06.

A materialidade delitiva do crime prevista no artigo 33, da Lei 11.343/06

evidencia-se pelo inquérito policial (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 04/06), auto de exibição e apreensão (fls. 07/08), termo de depoimento (fls. 09/10), termo de declarações (fl. 11), fotografias (fl. 13), laudo pericial (fls. 15/17; 20/22), registro de ocorrência (fls. 61/68), auto de qualificação e interrogatório (fls. 90/91), relatório final (fls. 95/96), bem como pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

A autoria também é certa. Vejamos.

Fernando Bertoni da Silva Francisco (testemunha comum) declarou que foram solicitados para ir ao bairro indicado, diante de informações de tráfico e uso de entorpecentes no local. AO entrar na rua, viram duas pessoas debaixo da árvore. Um dos indivíduos correu, enquanto o réu ficou ao local. Foi dispensado um objeto, posteriormente identificado como dinheiro (90 reais). Elson informou o local em que morava e disse que, dentro da casa, tinha uma porção para uso. Localizaram 3 porções de maconha. No corredor da casa, tinha uma balança de precisão. Ele foi conduzido em razão disso. O réu declarou não saber a procedência da balança, falando que deveria ser do outro indivíduo. Sobre o dinheiro, não se recorda o que foi dito. Em outras ocasiões, receberam denúncias citando o nome dele. Foi a primeira abordagem que realizou. A outra pessoa não foi identificada. Não se recorda quem dispensou o objeto. As denúncias indicavam que ele estaria usando a residência para uso e tráfico de entorpecentes. Não chegaram a repassar detalhes. Não se recorda se a balança de precisão tinha resquícios de drogas.

Paulo Henrique Modonese Costa (testemunha comum) disse que estava com o cabo Bertoni, fazendo patrulhamento na cidade. Foram informados sobre denúncias de tráfico de drogas, pelo bairro. Já conheciam o local como ponto de tráfico, inclusive com biqueiras. Quando entraram a rua, viram dois indivíduos debaixo de uma árvore. Um deles empreendeu fuga. O outro permaneceu no local. Viram que, naquele local, tinha uma quantia de dinheiro (90 reais). Elson disse que era apenas usuário e que tinha porções de maconha, autorizando o ingresso na casa. O imóvel dele era em frente à casa da abordagem. Parecia que somente ele vivia na casa ou que era usado como ponto de uso de drogas, pelo estado de conservação. Ele permitiu a entrada e encontraram outras três porções. O réu disse que era apenas usuário. Considerando as circunstâncias, conduziram-no até a delegacia. Na lateral da casa, foi encontrada uma balança de precisão. Elson disse que não era dele, mas a balança estava no corredor da casa (dentro do terreno da casa). O réu disse que apenas os entorpecentes pertenciam a ele. As denúncias indicavam o uso/tráfico de drogas nesse endereço. Não se recorda de outras abordagens anteriores. Não o conhecia. Não se recorda se ele dispensou no chão. Não se recorda se foi questionado a ele se o dinheiro pertencia a ele. Não se recorda se tinham resquícios de entorpecentes na balança. No caso específico, as informações diziam que, naquele endereço e nas proximidades, existia a traficância, não chegando a mencionar o nome do réu.

Elson Romeiro de Souza (réu) disse que 33 anos. Trabalha com obras. Ganha, em média, 400 reais por semana. É solteiro. Não tem filhos menores de idade. Já respondeu a outros processos. Disse que a maconha era sua, para uso própria. Não sabe de quem era a balança. Não se recorda se estava com outra pessoa no local. Não tinha dinheiro. Foi encontrado dinheiro, mas não pertencia ao depoente. Outras pessoas frequentavam a casa do depoente. Na época, era usuário de crack e maconha. As pessoas confundem, porque viam o movimento de pessoas que iam à casa do depoente para usar. Na época, não tinha atividade fixa, mas arrumava alguns bicos. A casa pertence à mãe do depoente. Sempre trabalhou com obras. Isso

Finda a instrução processual, o conjunto probatório é suficiente para fundamentar um decreto condenatório.

Na fase extrajudicial, o réu declarou que: “na data de hoje, por volta das 21h10, estava em frente a sua residência, momento que uma viatura policial passava pelo local, parou e lhe abordou. Que não sabe informa quem era o indivíduo que se evadiu ao ver a viatura policial, que estava próximo. Questionado nega qualquer ato de tráfico de drogas no local. Relata que é usuário de maconha, crack e cocaína. Que espontaneamente abriu sua casa para os policiais militares e no seu interior, no banheiro da residência, localizaram porções de maconha. Que não sabia que havia porções de maconha no banheiro, pois esqueceu havia deixado no local e eram pra consumo. Nega a propriedade da balança localizada na parte externa do imóvel e nega a propriedade do dinheiro localizado em frente a sua residência, não sabendo nem o valor localizado” (fl. 11).

Por sua vez, na fase judicial, o réu, novamente, disse que guardava as drogas para consumo próprio. Negou, entretanto, possuir uma balança de precisão. A versão do acusado está isolada nos autos e não encontra respaldo em qualquer prova produzida sob o crivo do contraditório.

A análise do crime de tráfico (artigo 33, caput, Lei 11.343/06) exige a avaliação de todas as circunstâncias do caso concreto. No caso, as circunstâncias da apreensão da droga, bem como o teor da prova oral produzida, demonstram que o acusado tinha a droga em depósito com a finalidade de comercialização.

Isto porque, ouvidos em juízo, de forma coesa e unânime, os policiais militares declararam que, durante fiscalização de ocorrência de tráfico, avistaram o réu e um indivíduo não identificado sob uma árvore, os quais, ao notarem a aproximação policial, tentaram fugir, sendo que somente o acusado foi abordado. Localizaram um objeto no chão, que se tratava da quantia de R\$ 90,00. Inquirido, o denunciado confessou propriedade de entorpecente em sua casa, alegando ser para uso próprio. Na sequência, franqueada a entrada no imóvel pelo réu, foram localizadas e apreendidas três porções de substância entorpecente e, na área externa da casa do denunciado, foi encontrada uma balança de precisão, que após realização de perícia, restou positiva para presença de resquícios de cocaína (fls. 20/22).

Nesse ponto, é inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento de policial deve ser sempre recebido com reservas porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório (RT 530/372).

A crítica costumeiramente expendida em relação ao depoimento de policiais carece de fomento jurídico, diante dos termos peremptórios do artigo 202 do Código de Processo Penal, cujos depoimentos, desde que verossímeis coerentes e não desmentidos pelo restante da prova, podem servir de base à decisão condenatória (RT 445/382). Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“Habeas Corpus. Processual penal. Tráfico de entorpecentes. Condenação devidamente amparada no conjunto probatório dos autos. Testemunho policial. Eficácia probatória. Valoração das provas. Impossibilidade na via eleita. Precedentes do STJ. 1. Ainda que a condenação tivesse sido amparada apenas no depoimento de policiais - o que não ocorreu na espécie -, de qualquer forma não seria caso de anulação da sentença, porquanto esses não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenha participado, no exercício das funções. Em sendo assim, tais depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória, principalmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório e aliado a outros elementos de prova a corroborar a condenação. 2. É inviável no presente writ a análise do valor das provas contidas nos autos para a condenação, uma vez que, além de ferir o princípio do livre convencimento do juiz, tal matéria escapa ao âmbito de apreciação do habeas corpus, em face da necessidade do exame minucioso do material cognitivo colhido no processo. 3. Ordem denegada” (HC 30776/RJ; Ministra Laurita Vaz, j. 03/02/2004, DJ 08.03.2004, p. 304).

De maneira semelhante, o Tribunal de Justiça de São Paulo:

“Com efeito, a palavra de policiais deve ser tida como verdadeira se não demonstrado no curso da persecução penal qualquer contradição relevante ou de elementos que indiquem relações inamistosas entre estes e o acusado em juízo, porque presunção “jûris tantum” de veracidade. Note-se que os participantes da operação não ofertaram nenhum ponto obscuro ou nebuloso que se faça presumir estejam criando estratagema para incriminar indistintamente inocente. Por consequência, infere-se, com a necessária segurança, que nada recomenda a colocação da pecha da suspeição nesses depoimentos. Agiram de maneira escorreita e sob o manto da legalidade, merecendo integral credibilidade seus depoimentos”. (Apelação criminal nº 993.07.048506-0 – São Paulo – 4º Câmara de Direito Criminal – Relator Paulo Rossi – registrada em 21/07/2010).

PORTE ILEGAL DE ARMA – Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade do delito em relação a ambos os réus – Validade da palavra dos policiais – Condenação mantida – Pena e regime bem impostos – Descabimento de concessão de qualquer benesse a Alexsandro – Recursos desprovidos (voto nº 29642). (Apelação 0000968-48.2015.8.26.0408. Relator (a): Newton Neves. Comarca: Ourinhos. Órgão julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal. Data do julgamento: 19/07/2016. Data de registro: 20/07/2016).

Não há qualquer indício de parcialidade no depoimento dos policiais, uma vez que o denunciado não soube apresentar razão apta a afastar a credibilidade dos depoimentos, especialmente no que tange à localização da balança de precisão. Ainda, a versão dos policiais é amparada pelo auto de exibição e apreensão e pelos laudos periciais acostados nos autos, os quais comprovam a apreensão da droga mencionada.

Observo que, para a caracterização do tráfico, não se analisa apenas a quantidade da droga, mas também as circunstâncias da apreensão. No caso, além da apreensão dos entorpecentes, os quais já estavam divididos em porções para a venda, o acusado foi encontrado em atitude suspeita, com indivíduo não identificado, que se evadiu da abordagem policial. Próximo ao local em que o réu estava, também foi encontrada quantia em dinheiro (R\$ 90,000), o que indica origem ilícita do numerário. Aliás, em fase policial, na mesma data de ocorrência, os policiais declararam que o dinheiro teria sido dispensado ao solo pelo acusado. Justificável que os policiais não tenham se recordado exatamente dessa situação, em razão do considerável decurso do tempo.

Cite-se, aqui, lição de FERNANDO DE ALMEIDA PEDROSO, segundo o qual “em sede de tráfico de substância entorpecente, constituem prova indiciária do malsinado e vil comércio, exemplificativamente, a quantidade apreendida de estupefacientes, denotando sua incompatibilidade com a destinação para o próprio uso; a forma de fragmentação e acondicionamento do tóxico, confeccionado em diversas embalagens ou unidades distintas e individuais, indicando o propósito de venda a varejo” (cf. “Prova Penal”, ed., RT, 2004, item 5, pág. 96).

No mais, também foi encontrado petrecho típico de tráfico de drogas, consistente em uma balança de precisão, a qual apresentava resquícios de cocaína (fls. 20/21). Tal fato comprova que o instrumento era utilizado para dividir e pesar entorpecentes, com a finalidade de venda. Aliás, essa circunstância está em consonância com as várias denúncias anônimas juntadas aos autos (fls. 61/68), segundo as quais o acusado comercializava não apenas maconha (que foi efetivamente encontrada), mas também cocaína/crack. Segundo as denúncias anônimas, a movimentação de tráfico ocorria há meses, naquele endereço, com comercialização feita por “Elcinho”, até mesmo com o uso de menores de idade como “olheiros” (fl.65). Soma-se a isso que o policial Bertoni ter conhecimento da existência de denúncias anônimas, informando que o réu estava envolvido com a prática de entorpecentes.

Sobre a posse de dinheiro e petrechos como elementos aptos a corroborar a prática do tráfico ilícito de entorpecentes, além da existência de denúncias anônimas, já se decidiu:

TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – APREENSÃO DE DROGAS VARIADAS, INDIVIDUALIZADAS

EM PORÇÕES E PRONTAS PARA VENDA NO VAREJO (DUAS PORÇÕES DE MACONHA PESANDO 287,5 GRAMAS E 7 PORÇÕES DE CRACK PESANDO 5,95 GRAMAS), ALÉM DE R\$ 340,00 EM DINHEIRO, FRUTO DA VENDA DE ALUCINÓGENOS, BEM COMO PETRECHO LIGADO AO NARCOTRÁFICO (BALANÇA DE PRECISÃO) – MERCANCIA COMPROVADA – CONDENAÇÃO CORRETA – PENA BEM DOSADA – REGIME ADEQUADO – NÃO PROVIMENTO DO APELO. (TJSP; Apelação Criminal 0006944-85.2018.8.26.0196; Relator (a): Willian Campos; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Franca - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/04/2020; Data de Registro: 29/04/2020)

TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRELIMINAR – Nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Inocorrência – Rejeição. MÉRITO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimentos dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório. Apreensão de considerável quantidade de entorpecentes (55 porções de cocaína, com peso de 29,8 gramas e 76 porções de maconha, com peso de 183,3 gramas), além de dinheiro e petrechos – Condenação mantida. PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases acima dos patamares. Quantidade de entorpecentes apreendidos. Exasperação na fração de 1/6. Proporcionalidade – Inviável o redutor do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. – Regime inicial fechado – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, art. 44, I e III) – Apelo provido em parte para reduzir as penas. (TJSP; Apelação Criminal 1502446-43.2019.8.26.0548; Relator (a): Gilberto Ferreira da Cruz; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Campinas - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 13/04/2020; Data de Registro: 13/04/2020).

É importante consignar que, segundo denúncias anônimas, a maior parte do entorpecente era armazenada em terrenos próximo e até mesmo em um campinho, e não na residência, procedimento realizado para tentar evitar a abordagem policial e a apreensão da droga. Portanto, a pequena quantidade de entorpecentes encontrada não pode ser analisada isoladamente.

Deste modo, todos os elementos de prova, analisados conjuntamente, demonstram, de forma inequívoca, que a substância entorpecente pertencia ao acusado e se destinava à venda.

A Jurisprudência dos Tribunais é clara no sentido de elencar alguns, dentre os vários elementos de convicção a evidenciar a condição de traficante. Confira-se:

“Constituem elementos de convicção, que evidenciam a condição de traficante, as denúncias anônimas, a quantidade da substância apreendida, a forma de sua embalagem, a conduta do réu no momento da apreensão e as circunstâncias em que se dá a prisão” (Ap. Crim. 152.279.3, 3ª Câmara, j. 19.06.95 Rel. Des. Bittencourt Rodrigues).

“Para a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes não é necessário que o agente seja surpreendido no exato momento em que esteja fornecendo materialmente a droga à terceira pessoa, bastando a evidência que para fins de mercância se destina o tóxico encontrado” (TJSP Ap. 187.915-3/2 Rel. CRISTIANO KUNTZ - RT 727/478).

“Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido (TJSP “RT”729/542), ou seja, não se exige prova flagrancial do comércio ilícito” (TJDF AC 13.847/94 Rel. Pingret de Carvalho DJU 3, 3.8.94, p.8745).

Vale ressaltar que, para a configuração do crime de tráfico de entorpecentes, basta a ocorrência de um dos verbos do tipo penal (artigo 33, Lei 11343/06), o que, neste caso, constitui o fato do réu guardar e ter em depósito o entorpecente apreendido pelos policiais, com o objetivo de vendê-lo, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O crime de tráfico ilícito de drogas é de natureza permanente, que se consuma com a simples posse pelo agente, para fim de entrega a terceiro, sendo, portanto, desnecessário que seja flagrado vendendo a

droga.

Além do mais, pode coexistir, na mesma pessoa, a figura de traficante e usuário. O fato de, eventualmente, ser usuário de substância entorpecente não obsta ao reconhecimento da figura de traficante. Ao contrário, é natural que ambas as condições, a de usuário e a de traficante coexistam, pois, com a arrecadação obtida com a venda do entorpecente, possibilitar-se-á o emprego na compra, para que o vício possa ser sustentado.

Outrossim, a alegação de usuário ou de “viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam no mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade” (RJTJESP 101/498). Portanto, nesse ponto a condenação é medida de rigor.

Por outro lado, melhor sorte não assiste ao delito previsto no artigo 34, da Lei 11.343/06. Isso ocorre porque reputo não se vislumbrar contextos autônomos e coexistentes que vulnerem de modo significativo e distinto o bem jurídico tutelado. É fato que foi apreendida uma balança de precisão, equipamento utilizado para a pesagem das drogas (fls. 07/08). Nesse sentido, concluiu o laudo pericial de fls. 20/22: “A análise do material descrito fez o uso de teste colorimétrico e Cromatografia em Camada Delgada (CCD) e, dentro das condições analíticas empregadas, foi DETECTADA presença da substância COCAÍNA, constante na lista F1 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020)”.

O Ministério Público considerou que a apreensão de balança contendo resquícios de entorpecente constitui material notoriamente empregado para preparar e embalar entorpecentes destinados à venda, que exigem pesagem precisa, o que caracterizaria o crime autônomo.

Entretanto, ressaltado e respeitado esse entendimento, uma vez comprovado o tráfico de drogas, a mera posse de balança de precisão, ainda que apreendida com resquícios das drogas nela preparada, caracteriza meio normal para a execução ou exaurimento do delito-fim tencionado pelos agentes e capitulado no artigo 33, da Lei n. 11.343/06. Assim, o delito de tráfico deve absorver a conduta imputada com fundamento no artigo 34, do mesmo diploma legal.

É certo que os tipos penais revelam naturezas distintas. Porém, é necessário reconhecer o caráter subsidiário do artigo 34, da Lei de Drogas, de modo que a posse do objeto utilizado pelos agentes com o objetivo de preparar a droga para que fosse comercializada posteriormente fique sujeita ao princípio da consunção, restando o crime-meio absorvido pelo crime-fim.

Este é o teor de farta jurisprudência do Tribunal Bandeirante:

APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Artigos 33 e 34, da Lei nº 11.343/06 – Pleito de absolvição – Aplicação do princípio da consunção – Tipo penal subsidiário que resta absorvido pelo crime de tráfico de entorpecentes – Absolvição em relação a esse delito – Materialidade e autoria comprovadas nos autos em relação à conduta prevista no artigo 33, da mesma lei – Condenação mantida – Impossibilidade de aplicação do redutor previsto no artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343/06 – Dedicção do réu a atividades criminosas – Descabimento da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos – Regime prisional inicial fechado que se mostra adequado à espécie – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1501089-45.2020.8.26.0628; Relator (a): Fátima Gomes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Embu das Artes - 2ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 30/11/2021; Data de Registro: 30/11/2021)

Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença absolutória quanto ao crime do art. 34, da Lei nº 11.343/06, e condenatória pelo art. 33, caput, também da referida Lei. Recurso Ministerial, buscando a condenação do réu também como incurso no art. 34, da Lei de Drogas. Materialidade e autoria comprovadas – Prisão em flagrante delito – Apreensão de mais de 4kg (quatro quilogramas) de maconha – Depoimentos dos policiais civis coesos e harmônicos entre si e em relação àqueles prestados perante a Autoridade Policial – Descrição precisa da prática da

traficância de drogas pelo acusado, que foi flagrado enquanto transportava entorpecentes dentro de um veículo – Réu que confessou o crime de tráfico – acusado que franqueou a entrada dos Policiais em sua residência, o que culminou na apreensão de uma balança de precisão – objeto que se mostra como mero instrumento para a consecução do crime tráfico de drogas no caso concreto – ausência de outros petrechos para o tráfico na residência do acusado – princípio da consunção devidamente aplicado na r. sentença e que deve ser mantido em sede de julgamento do recurso de apelação – inviabilidade de condenação pelo delito do art. 34, da Lei nº 11.343/06. Dosimetria da pena – Pena-base bem fixada acima do mínimo legal, diante da elevada quantidade de drogas apreendidas. Inteligência do art. 42 da Lei 11.343/06 – Na fase intermediária, redução ao mínimo legal, diante da confissão espontânea – Na terceira fase, ausentes causas modificativas – redutor de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas incabível, uma vez que ausentes os requisitos legais. Fixação de regime inicial fechado, único compatível com o delito em tela, diante da alta gravidade e reprovabilidade da conduta do réu, em concreto – Impossibilidade de substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos, porque falta amparo legal e em virtude das circunstâncias também não recomendarem a substituição – Tratamento incompatível com os objetivos da Lei de Drogas. Recurso Ministerial desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 1501895-65.2020.8.26.0536; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Praia Grande - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/03/2022; Data de Registro: 21/03/2022)

Quanto a esse delito, a absolvição é devida, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Verifico que o réu é reincidente e ostenta maus antecedentes, pois possui mais de uma condenação transitada em julgado anterior à data dos fatos (fls. 133/138). Consigno que não se aplica o prazo depurador da reincidência para a caracterização de maus antecedentes.

Nesse contexto, comprovadas a autoria e materialidade, de rigor a condenação do acusado. Passo à dosimetria a pena.

Artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006

Na primeira fase, atendendo aos critérios do artigo 59 do Código Penal, verifico que o acusado é portador de maus antecedentes. As demais circunstâncias do artigo 59, CP são comuns aos delitos dessa natureza. Por essa razão, aumento a pena-base em 1/6, fixando-a em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes e presente a agravante da reincidência.

Aumento a pena em 1/6 e fixo a pena intermediária em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e aumento da pena. Torno a pena definitiva em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

Ressalto que é inviável a aplicação da causa de diminuição de pena, pois o acusado é reincidente e portador de maus antecedentes.

Ausentes elementos sobre a condição econômica do réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal (1/30 do salário-mínimo), devidamente atualizado, nos termos do artigo 49, § 1º 2º, CP e artigo 43, Lei 11343/06.

O regime inicial para o cumprimento da pena de prisão é o fechado, pois o acusado é reincidente e portador de maus antecedentes. Não há informações sobre tempo de prisão provisória para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena.

Destaca-se que, apesar da declaração de inconstitucionalidade da expressão “vedada a conversão em penas restritivas de direitos” constante do §4º do art. 33, e da expressão “vedada a conversão de suas penas em restritivas de direito”, constante do art. 44, da Lei 11.343/2006 (STF, HC 97.256/RS), o caso dos autos não permite a substituição da pena de prisão por penas alternativas/aplicação da suspensão condicional da pena, ausente o requisito objetivo do art. 44, I, do Código Penal, que estabelece pena privativa de liberdade não superior a quatro anos, além de ausentes os requisitos subjetivos.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para CONDENAR o réu ELSON ROMEIRO DE SOUZA, portador do R.G. n.º 46.259.474, filho de José Donizete de Souza e Luiza Aparecida Romeiro de Souza, nascido em 05/01/1989, às penas de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial FECHADO, e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor mínimo legal, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, e artigo 34, ambos da Lei n.º 11.343/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Poderá o réu apelar em liberdade neste processo, não estando presentes os requisitos da custódia cautelar (artigo 312, CPP).

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, que serão exigíveis na forma da lei, observado o disposto no artigo 98, §3º, CPP.

Caso ainda não se tenha procedido na forma do artigo 50-A da Lei 11.343/06, determino a destruição das drogas apreendidas, inclusive das amostras guardadas (artigo 72, Lei 11.343/06).

Após o trânsito em julgado: oficie-se ao Instituto de Identificação Civil; comunique-se ao TRE para cumprimento do disposto no artigo 15, III, CR; expeça-se guia de execução definitiva, observando-se o regime inicial fixado nesta sentença; realizem-se as anotações e comunicações de praxe, arquivando-se os autos, oportunamente.

6. Em seguida, pelo(a) Dr(a). Promotor(a) foi dito que não haveria interposição de recurso por parte do Ministério Público. Em seguida, pelo(a) Dr(a). Defensor(a) foi dito que: requeira vista para apresentação das razões de apelação. Em seguida, pela MMª. Juíza de Direito foi dito que: Certifique-se o trânsito em julgado para o Ministério Público. Recebo o recurso de apelação interposto pela defesa, e concedo o prazo de 08 (oito) dias para apresentação das razões de apelação. Em seguida abra-se vista ao Ministério Público para apresentação de contrarrazões. Expeça-se certidão de honorários ao advogado nomeado, se for o caso. Após, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça com nossas homenagens de estilo.

7. PUBLICADO EM AUDIÊNCIA. SAEM OS PRESENTES INTIMADOS. SERVIRÁ A PRESENTE POR CÓPIA DIGITADA COMO MANDADO/OFÍCIO. Nada mais. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. José Bonifácio, 25 de outubro de 2022. Eu, Augusto César Cristal Lopes, Escrevente Técnico Judiciário, digitei e subscrevi. Meritíssima. Juíza - Documento assinado digitalmente nos termos da lei 11.419/2006, conforme impressão à margem direita.